

الأساس المنطقي في التمييز بين الإسناد الكاشف

طبيعة الواقعة وتوصيفها

الدكتور/ محمد سليمان الأحمد

أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة المملكة - مملكة البحرين

١- غالباً ما تتضمن الدراسات القانونية، فضلاً عن التعريف بموضوع الدراسة، تحديد الأساس القانوني له، أو تأصيله قانونياً، أو توضيح النظام القانوني للموضوع، أو تعيين الأوضاع القانونية؛ أو تعمق الدراسة القانونية لتبين التكييف القانوني للموضوع، أو تحديد طبيعته القانونية. لكن غالباً ما يذهب قصد الباحثين إلى إعطاء معنى التكييف القانوني للطبيعة القانونية أو العكس، على الرغم من وجود الفارق بينهما. ويظهر الفارق بين هذين النمطين في علم القانون عندما نحدد نطاق تطبيق القانون المراد تطبيقه على الواقعة في كافة مراحل التطبيق؛ والقانون المراد تطبيقه على الواقعة ليس قانوناً واحداً لجنس واحد من الوقائع، بل هو يختلف باختلاف طبيعة الواقعة فهل هي واقعة ذات طبيعة مدنية أم جنائية أم تجارية..... إلخ؛ ثم أنه -أي القانون المراد تطبيقه- يختلف باختلاف صنف الواقعة بالنتيجة التي آل إليها تكييفها، وبالتالي فإن القانون المراد تطبيقه مرتبط بتكييف الواقعة وتحديد طبيعتها القانونية، وهنا تكمن أهمية البحث الذي سنعالجه في المباحث الأربعة الآتية :-

-المبحث الأول : البحث في الاختصاص.

-المبحث الثاني : ماهية التكييف.

- المبحث الثالث : ماهية الطبيعة القانونية .

- المبحث الرابع : العلاقة بين التكييف والطبيعة القانونية .

ثم ننهي البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات

الأمم المتحدة الإنمائي، القاهرة، سنة ٢٠٠٣م.

(11) Louis Favoreiw : the principle of equality in the jurisprudence of the Conseil Constitutional. Capital University Law Review .2001

(12) Cynthia A.Vroom: Equal protection versus the principle of equality. American and French views . on Equality in the law . Capital University law Review . 2000.

(13) J. Robert. les violations de la liberté individuelle commises part la administration. L . G . D . J .. 1956 .

(١٤) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٧، لسنة ٩ قضائية دستورية، جلسة ١٩ مايو، سنة ١٩٩٠م، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الرابع.

(١٥) حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم ٢٨، لسنة ١٠ قضائية دستورية، جلسة ٤ مايو، سنة ١٩٩١م، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الرابع.

(١٦) حكم المحكمة الدستورية المصرية، القضية رقم ٣١ لسنة ١٧ قضائية دستورية، جلسة ٢ يناير، سنة ١٩٩٩م، الجزء التاسع.

(١٧) حكم المحكمة الدستورية البحرينية، الحكم الثالث عشر، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٠٩م، في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٦/٢ لسنة (٤) قضائية، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ٢٠٠٩ في العدد رقم ٢٨٨٩، مملكة البحرين.

(١٨) حكم المحكمة الدستورية البحرينية، القضية رقم د/٦/٣ لسنة ٤ قضائية دستورية، قاعدة رقم ٦، جلسة ٣٠ مارس ٢٠٠٩.

(١٩) حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، في ٢٩/٤/١٩٨٩، طعن ٥٧/٢١ دستوري، القاهرة، سنة ١٩٨٩م.

(٢٠) حكم المحكمة الدستورية البحرينية، القضية رقم د/٦/٣ لسنة ٤ قضائية دستورية، قاعدة رقم ٦، جلسة ٣٠ مارس ٢٠٠٩.

(٢١) حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، في ٢٩/٤/١٩٨٩، طعن ٥٧/٢١ دستوري، القاهرة، سنة ١٩٨٩م.

(٢٢) حكم المحكمة الدستورية البحرينية، الحكم الثامن عشر، في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٧/٤ لسنة (٥) قضائية، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩ في العدد رقم ٢٩٢٨، مملكة البحرين

(٢٣) المبدأ رقم ١/١١، مجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية، الكتاب الثاني

المبحث الأول

البحث في الاختصاص

٢- يلاحظ أن كل علاقة قانونية ينشأ عنها نزاع معين ، تحتاج إلي قانون مختص بالتطبيق عليها ، إذ إن القاضي لا يستطيع إلا أن يقضي بقانون أو بموجب قانون ؛ فما المقصود بالقانون المختص بالتطبيق ؟ القانون المختص بالتطبيق هو القانون الموضوعي(١) الذي يحتوي على الحكم القانوني الخاص بفرضية الواقعة ، وفرضية الواقعة تشمل شقين :-
الأول: الفرضية المذكورة في القاعدة القانونية والتي ينص عليها المشرع عادة ويضع لها حكماً مناسباً(٢) .
الثاني: الواقعة ذاتها بكل عناصرها وظروفها الحاصلة والمعروضة على القاضي ، والتي بها تحولت فرضية الواقعة من مجرد فرضية افترضها القانون إلي واقع حاصل حادث.
٣- إن القانون المختص بالتطبيق يختلف عن القانون الواجب التطبيق المعروف في القانون الدولي الخاص ، إذ إن وجوبية تطبيق الأخير، تنبع من وجود حالة تنازع القوانين ، كأن يرم شخص عراقي في الأردن عقداً مع شخص سوري لغرض تنفيذه في لبنان ، فأَي من هذه القوانين هو الواجب التطبيق على هذا التصرف (الواقعة بمعناها العام) ، أهو : القانون الأردني ، قانون دولة محل الإبرام ؛ أم القانون العراقي ، قانون دولة المتعاقد الأول ؛ أم القانون السوري ، قانون دولة المتعاقد الآخر ؛ أم القانون اللبناني ، قانون دولة تنفيذ العقد ؟

هنا يأتي دور قواعد الإسناد (٣) لتبين القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة المشوبة بعنصر أجنبي ؛ أما القانون المختص بالتطبيق فهو القانون الذي يحتوي على حكم فرضية الواقعة ، وهنا ينبغي التمييز

(١).القاعدة الموضوعية هي القاعدة التي تقرر حقاً أو تعدله أو تغيره أو تلغيه ، فهي قاعدة تؤثر في المراكز القانونية ؛ وتقابلها القاعدة الإجرائية أو الشكلية .(لاحظ مؤلفنا : تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية ، دار وائل للنشر ، عَمَّان ٢٠٠٤ ، ص٥٣).

(٢).تتكون القاعدة القانونية من عنصرين مهمين هما : الفرضية والحكم ؛ إذ أن الفرضية تقتض وقوع حدث في المستقبل يرتب عليه القانون حكماً ، وهذا الحكم هو الجواب على السؤال المفترض في الفرضية .(لاحظ للتفصيل بحثنا: عناصر القاعدة القانونية (الفرضية والحكم) ، مجلة الراصد للحقوق ، كلية القانون جامعة الموصل ، العدد الخامس، أيلول ، ١٩٩٨ ، ص١٠٤ وما بعدها) .

(٣).قواعد الإسناد هي مجموعة القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات الفعصر الأجنبي ، فهي قواعد تواجه المراكز أو العلاقات الداخلية فيما يسمى بالحياة الخاصة الدولية (تعريف الأستاذ الدكتور شمس الدين الوكيل ، نقلا عن الدكتور هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٧٥ ، ص٤) .

بين القانون بمعناه العام والقانون بمعناه الخاص(١) ، إذ كثيراً ما يلتبس على البعض التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص من جهة ، والقانون بمعناه العام والقانون بمعناه الخاص من جهة أخرى، نظراً لكثرة الاهتمام بفرعي القانون على حساب معنياء. القانون بمعناه العام ، يقصد به مجموعة القواعد القانونية المرعية في مجتمع ما والمنظمة للعلاقات الاجتماعية فيه والتي يلتزم الأشخاص باتباعها ، ولأ تعرضوا للجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة ، كأن يقال القانون الفرنسي والقانون البحريني .. الخ . أما القانون بمعناه الخاص فيعني مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة المختصة بالتشريع في دولة ما لتنظيم أمر معين(٢)، كأن يقال : القانون المدني ، القانون الجنائي ، قانون الضرائب ، ... الخ . وفائدة التمييز بين القانون بمعنييه العام والخاص تكمن في التمييز بين القانون الواجب التطبيق والقانون المختص بالتطبيق ، فالقانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين هو قانون بمعناه العام ، أما القانون المختص بالتطبيق فهو قانوناً بمعناه الخاص عموماً .

٤- إن القانون المختص بالتطبيق هو القانون الذي احتوى على القاعدة القانونية التي فيها فرضية الواقعة والحكم الموضوع لها ، إذ إن القاضي عندما تعرض عليه واقعة معينة ، فإنه يتوجب عليه وحده (٣) أن يبحث ويفتش عن فرضية هذه الواقعة في مختلف القواعد القانونية حتى يجد لها حكماً مناسباً يطبقه عليها . وهذا يعني أن القانون المختص بالتطبيق هو القانون الذي له خصوصية التطبيق على هذه الواقعة ، لا بمعنى أنه يختص بالتطبيق على هذه الواقعة دون غيرها ، بل بمعنى أن الواقعة قد انحصرت تطبيق هذا القانون عليها دون غيره ، ثم أن هذا لا يعني حتمية وجود قانون واحد مطبق بمفرده على مفردات الواقعة ، بل قد تعددت فقرات الواقعة فيختص كل قانون بالتطبيق على كل فقرة من فقرات هذه الواقعة ، كأن يتعرض قاضي محكمة البداية لواقعة تشتمل على عمل تجاري وإخلال بتنفيذ التزام موجب لنهوض المسؤولية المدنية ، فهنا يتحتم على القاضي تطبيق القانون التجاري على الفقرة التجارية ، كما أن عليه تطبيق القانون المدني على الفقرة المدنية الواردة في الواقعة ؛ لكن كيف يحدد جنس الفقرة ، فعلى أي أساس يضي الصفة المدنية أو التجارية أو غيرها على هذه الفقرة أو تلك في الواقعة ؟ هذا ما سنجيب عليه في ماهية الطبيعة القانونية . ثم كيف سيحدد نوع ما تشتمل عليه الفقرة ، فهل هذه المسؤولية من قبيل المسؤولية العقدية أم أنهاغير عقدية (تقصيرية) ؟هذا ما سنجيب عليه في تحديد ماهية التكييف القانوني.

(١). لاحظ: د. توفيق حسن فرج ، د. محمد يحيى مطر ، الأصول العامة للقانون ، الدار الجامعية، بيروت ، ١٩٨٩ ، ص ١٤ ، عبد الباقي البكري و د. علي محمد بدير وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٨٧ ، ص ١٧ . د. سعيد مبارك ، أصول القانون، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٨٢ ، ص ١٧ .
(٢). لاحظ: عبد الباقي البكري و د. علي محمد بدير وزهير البشير ، المرجع السابق ، ص ١٧ .
(٣) . القاضي دائماً هو المعني بإثبات القانون أيأ كان وطنياً أو أجنبياً (لاحظ: الأستاذ مصطفى كامل ياسين ، كيف يُطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٥٧ ، ص٨٠. أ.د. عباس العمودي ، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٩٢ ، ط٢ ، ص٢٣ ، وكذلك أ.د. عباس العمودي ، شرح أحكام قانون البينات الجديد ، دار الثقافة ، عَمَّان ، ٢٠٠٤، ص٢٤ وما بعدها) .

المبحث الثاني

ماهية التكيف

5- بعد التكيف القانوني عملية قانونية ، تكون في أحيان معينة ، معقدة جداً ، فالتكيف في القانون يقابل التشخيص (تشخيص المرض) في الطب ، إذ يتم الاعتماد عليه في تطبيق حكم القاعدة القانونية على فرضيتها الممثلة في الواقعة الحاصلة التي وضعها التكيف ضمن إطار الفرضية الموضوعة من قبل المشرع.

والتمييز القانوني هو عمل قضائي أولاً ، ثم أنه عمل فقهي ثانياً (١) : فهو من حيث أنه عمل قضائي يقوم به القاضي بإعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة المعروضة عليه لتطبيق الحكم القانوني الملائم عليها : كما أنه عمل فقهي يقوم به الفقيه بتصنيف الوقائع حسب أوصافها ، فيجمع عدداً منها ويضعها في مجموعة واحدة ثم يقوم بتسمية هذه المجموعة ليتم من بعد ذلك إدراج الوقائع المماثلة . وهذا ما جعل البعض يطلق لفظ التصنيف على التمييز (٢) .

٦- وبعيداً عن الخوض في تفاصيل تعريف التكييف في اللغة والفقه والقانون (٣) ، نشير إلى أن كلمة (تكييف) على وزن (تفعليل) ، أي أن الذي يقوم بهذا الفعل هو الذي يجعل موضوع الفعل (متكيفاً)

(١) يذهب البعض إلى تقسيم الكيفيات إلى ثلاثة أنواع: فقهية وقضائية وتشريعية (انظر: هدى سالم الأطرجي، *القياس في الفقه الإسلامي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٠، ص ٢٣).

والمرجع إلى أضافته إليها، نرى نحن أن التعريف لا يمكن أن يكون تشريعيًا. لأن من يقوم بعملية التعريف هو المفسر والقاض، وإنما يستند إلى وصف المشرع أي كان هذا الوصف أو نوعه أو عرضه، فالشعر ينشأ الأوصاف في نماذج (أو الوال) - سَمًا ما شئت -، وباتى دور القائم على عملية الكيفيات لمعنى القانونى السليم للواقعة، وكأنا

بعض الأواب - (الفاصل) الصحيح.

(٢). سامي عبد منصور، د. عاكشة عبد الحلال، القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة، بيروت، ١٩٩٥، ص٨٤.

(٣). للتفصيل في تعريف التكيف في القانون، انظر ٧٨، سامي عبد منصور، الوضع القانوني لعودة التاميين لاعتبار كالتاميين المقيمين بالخارج، كلية القانون، جامعة الموصل، ١٩٩٧، ص٩٨٠. وبموجها لتدريسي الدكتور، السؤلية التاميين للامانة للمسلمين.

(٤). في تنظيم الأنشطة الرياضية، كلية القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٠، ص١٦٤، وبمعدا. (و للتكيف في القانون الدولي الخاص، دورهم في علاج منعه، في هذا القانون لاحقاً: د. شاميل علي صادق، مرقس سبق ذكره، ص ١١١. د محمد الدكامل عامر، أصول القانون الدولي الخاص، دار القانون، الاسكندرية، ١٩٥٥، ص٢٢٧. (يلاحظ ان الدكتور عز الدين عيسى، كان قد عرف التكيف بأنه: (تحديد طبيعة العلاقة القانونية ردوها لنظام قانوني من ضمنه التاميين بقاعدة القانون). وذلك في الطبعين الأولى والثانية من مؤلفه (القانون الدولي الخاص)، إلا أنه عدل عنه في الطبعات الأخرى).

(٥). القانون الدولي الخاص، مؤلفه: (٣) الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩، ط٤، ص ١١٢ وبمعدا. لاحقاً.

(٦). روجه الخصيص، ص ١٤٤، والهاماش ج.

(٧). الصفة العامة للتكاثب.

(كما أن التكيف قد حظي باهتمام المختصين في القانون الجنائي وقد فاضوا في الكتابة في هذا الموضوع الحيوي) لاحظ المزيد من التفاصيل : د. هدى سالم الأطرجي ، أطروحتها سبق ذكرها ، ص ٢٢ وما بعدها.

(كما أن التكيف قد حظي باهتمام المختصين في القانون الجنائي وقد فاضوا في الكتابة في هذا الموضوع الحيوي) لاحظ المزيد من التفاصيل : د. هدى سالم الأطرقيجي ، أطروحتها سبق ذكرها ، ص ٢٢ وما بعدها .

الحكم القانوني معين، وهنا تطبق المقتولين الآخرين في الفلسفة، مقولتي الفعل والانفعال (١)، فالتكليف هو فعل من خارج الواقعة به تتناول الواقعة لتدخل في حيز القانون، وهو يختلف عن الوصف القانوني في ذاته، فالتكليف هو عملية لإعطاء هذا الوصف الذي يعد نتيجة ترتب على هذه العملية القانونية الصرفة، هذه العملية تؤدي إلى وضع الواقعة في قالبها القانوني الصحيح؛ وهنا لا بد من التعرّيج على مسألتي هما: (١) هل القيد فيما لو لم يوجد نموذج (قالب) القانوني توصف به الواقعة؟ (٢) أم مشكلة لدينا عندما نتعدد مصادر القانون، أو كالمشكل تظهر عليه في القانون الجنائي التي يعتمد على مصدر واحد للتطبيق أو التشريع فقط، وهنا يرى البعض (٢) أن على المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بالبراءة لعدم وجود وصف قانوني لهذه الواقعة، ونحن نرى أن البراءة جاءت من تكليف الواقعة فعلاً مباحاً، لأن إصدار الحكم لا بعد الفراغ من عملية التكليف أي كانت نتيجتها، ثم أن علينا أن نميز بين النموذج القانوني والنموذج الواقعي والإجرامي أو النموذج القانوني للجرمة، فالنموذج الأول يخص توصيف الواقعة تجريباً أو إباحة سواء أكانت الإباحة طبيعية أم استثنائية (٣)، أما النموذج الثاني فانه يخص الواقعة تجريباً أو إباحة كإكسالص، ثم إباحته استثنائية فقط إذا توافر سبب من أسباب الإباحة (٤)، لأن عدم انطباق النموذج الإجرامي على الواقعة يجعلها مباحة إباحة طبيعية وبالتالي لا يطبق قانون العقوبات عليها؛ عليه فالمبررة بالنموذج القانوني للواقعة أي كان حكمه.

(ب). هل أن التكليف يعني إسناد الواقعة إلى شخص ما ؟ على الرغم من أن البعض (٥) يرى أن التكليف للإسناد ، لكنني أرى غير ذلك ، فالإسناد له معنى آخر في القانون ، لا سيما في القانون الجنائي (٦) . يختلف عن معنى التكليف الذي يقتصر دوره على إعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة ، وهذا دور كبير لا يقلل من شأنه خروج دور الإسناد منه ، والذي يقتصر على بيان نسبة الفعل إلى الفاعل بإسناد

(١). المولات العشر في ميث القيم (الأكسيولوجيا) هي: الكم، الكيف، الإضافة، الأين، المتي، الوضع، الملك، الفعل، والانفعال. (لاحظ: د. امام عبد الفتاح امام، محاضرات في المنطق، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٧٣، ص ٨٩).

(٢). وقد نظم بعضهم بيتين ذكر فيهما أمثلة المولات العشر ليسهل حفظها، قال:

زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان (متكي)

فہرہ سیف لواہ فالتوی فہرہ عشر مقولات سوی

فزيد مثال الجوهر، والطويل للكم، والأزرق للكيف، وابن للإضافة، وفي بيته للآين، والأسلم للمتي، ومتكى للوضع، وفيه ياء سيف للملك، ولواء للفعل، والتي للانفعال. (لاحظ: محمد جواد مغنية، معالم الفلسفة الإسلامية، مكتبة الهلال، بدون مكان وزمان النشر، ص ٦٥).

(٢). لاحظ المراجع التي أشارت إليها د. هدى سالم الأطرقجي، أطروحتها للدكتوراه سبق ذكرها، ص ٢٥.

(٢). في التمييز بين الإباحة الطبيعية والإباحة الاستثنائية، لاحظ: د. عبد الرؤوف مهدي، الاتجاهات المعاصرة في أساس ونظام إباحة الجريمة الرياضية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، القاهرة، العدد ٣، السنة ٢٧، ١٩٨٣، ص ١١.

(٤). لاحظ: د. عبد الرؤوف مهدي، بحثه السابق، ص ١١، ولاحظ: د. محمد سليمان الأحمد و د. نضال ياسين حمو، المنشطات الرياضية، دار جهيئة للنشر، عمان، ٢٠٠٣، ص ١٦.

(٥) . د. هدى سالم الأطرقجي ، أطروحتها سبق ذكرها ، ص ٢٥ .

(٦). لاحظ: د. رؤوف عبید، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٤، ط٤، ص٣.

مادي كان أو معنوي(١) . كما أن التكيف يختلف عن الإسناد القانوني الذي يتعلق بإسناد واقعة تتنازع عدة قوانين بشأن التطبيق عليها ، إلى أحد هذه القوانين ، سواء أكان التنازع بين قوانين عدة دول أو بين قوانين مختلفة في داخل الدولة ، وسنبين وجه الاختلاف عند البحث في ماهية الطبيعة القانونية .

٧- والتكيف القانوني يتصف ، عموماً ، بالصفات الآتية :-

أ- أنه عمل قانوني ، يتم به إعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة (بمعناها العام) المعروضة على القاضي أو الفقيه ، فهذا العمل لا يحاكي طبيعة الواقعة ، بل يحاكي مفرداتها ومدى انسجامها مع القوالب القانونية الموضوعية من قبل القانون ، إذ إن القانون يضع أوصافاً معينة لوقائع يفترض وقوعها في المستقبل (٢) لكن دون أن يدخل في تفصيلات الواقعة الحياتية الحاصلة فعلاً في الواقع والتي تخرج من مدركات الافتراض منطقاً ، لا رغبة من المشرع بل لأن تفصيلات الواقع متنوعة وكثيرة وغير متناهية (٣) ، وبالتالي فالمشرع لا يستطيع استيعاب كل ما سيقع في المستقبل ، فكل ما يفعله هو وضع (القوالب) -إن صح التعبير- ، فيأتي دور القاضي أو الفقيه أو من يقوم بهذه المهمة (٤) ، بإدراج الواقعة الحاصلة الحادثة ووضعها في قالبها المناسب . فالوصف موضوع من قبل القانون ، ووضعها هنا للأوصاف لا يعني أنه يكيف الوقائع -كما سبق أن ذكرنا- بل لكون من يضع الأوصاف أصلاً إنما يقوم بالتشريع ، أما من يطبق هذه الأوصاف على الواقعة ، فإنه يقوم بالتكيف لأنه لا يضع بل يعطي وصف القانون ، وهذا أيضاً ما يدل على اتصاف الوصف بالقانوني .

ب- التكيف هو عملية (قنونة) الواقعة ، إذ إنه عن طريق التكيف القانوني تتحول الواقعة من مجرد مسألة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ما تشاكل ذلك ، إلى مسألة قانونية ؛ و(القنونة)- إن صح التعبير- أعني بها صهر الواقعة بمفرداتها وملابساتها ، وجعلها واقعة مؤهلة لتطبيق القانون عليها ، فالتكيف هو تأهيل الواقعة لتطبيق القانون عليها .(١)

ج- التكيف عملية مهيّدة لتطبيق القانون ، وقد يكون التكيف أول ما يبدأ به التطبيق ؛ وقد ذكرنا أن التكيف يشبه التشخيص في الطب ، فالمطبيب لا يستطيع أن يعالج ما لم يشخص المرض ، والمعالجة القانونية لأية مشكلة لا تتم إلا بإعطائها الوصف القانوني السليم الملائم لتطبيق الحكم عليها .

د- التكيف عملية ، فضلاً عن أنها تهديدية ، فهي حتمية ؛ إذ يتحتم دائماً وأبداً تكيف الواقعة تمهيداً لتطبيق حكم القانون عليها ، سواء أكان هناك لبس أم لم يكن . فالأشخاص ، وهم أحد أهم عناصر الغالبية العظمى من الوقائع ، لا يدركون حقائق المعاني القانونية للألفاظ والكلمات المستخدمة في معاملاتهم بصورة عامة ، لكن المختص بعملية التكيف يحاكي مفردات الواقعة ويدرجها ضمن فرضيتها القانونية لتطبيق الحكم عليها ، وهذا الأمر حتمي في كل وقت وحين في نطاق تطبيق القانون المختص .

هـ- التكيف هو عمل يختص به قاضي الاختصاص ، إذ لا تكيف لواقعة غير معروفة بطبيعتها القانونية ، فهذه الواقعة لا يعرف ما قانونها المختص بأمثلها ؛ فعملية معرفة كون هذه المسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية ، ليست بتكليف ؛ وعملية معرفة كون هذا العقد مدنياً أو تجارياً أو إدارياً ، ليست بتكليف ؛ وعملية معرفة كون دفع هذا المبلغ أو ذلك على سبيل الغرامة أو التعويض أو الضريبة ، ليست تكليف ؛ لأن ما يميز

(١) في بحث منشور لنا ، ميزنا بين القنونة و (القنونة) ، فالقنونة تعني ، أنها التدخل القانوني في بعض الأوضاع غير القانونية ، وغير القانونية بمعنى أنها ، إما كانت غير مشروعة ، فشرّعها القانون ، كما في الزواج المثلي وتعامل المخردرات ، حيث يقال قنونة الزواج المثلي أو قنونة تعامل المخردرات ، في قوانين البلاد التي قونتت مثل هذه الأوضاع . أو أنها أوضاع ، وإن كانت مشروعة ، لكن القانون لم ينظمها بعد . مثلاً قنونة التظاهرات ، وقنونة التوقيع الإلكتروني ، وغيرها . فالقنونة هي تحول الأوضاع من أوضاع غير قانونية الى قانونية ، عبر قيام التشريعات بتنظيمها وإقرارها وحمايتها ، لكن ما تنصده الـ (قنونة) ، يتباين مع ذلك ، وإن كان قريباً منه في المعنى ، فالعقد ليس بالوضع غير القانوني لكي يحتاج الى قنونة ، بل هو لا يحتاج إليها أصلاً ، إنما هو وضع لا يقدر القانون على نكرانه أبداً ، لكن القانون جمل وسيلة لوضع بند عقدي مفترض فيه يعبر عن الإرادة العقدية العامة ، عن طريق فتح قناة في العقد ، والقناة التي يفتحها القانون في العقد ، لا شك أن أفضل مصطلح للتعبير عنها يتمثل في الـ ((قنونة)) ،، إذن فالـ (قنونة) هي قناة يضمها القانون في العلاقات العقدية عموماً ، وفي بعضها على وجه الخصوص ، لإعتبارات معينة ، تعبيراً عن الإرادة العقدية العامة ، لتحقيق مصلحة عقدية جماعية تمثل في الأساس في منع كل عقد من أن يحقق لطرفيه مصالح على حساب الإضرار بالجماعة ضرراً لا يقره المبادئ لأنفسهما وهما يبرمان عقدهما المشترك . وإن كان مصطلح الـ(قنونة) غير دارج في لغتنا العربية لكنه بالإمكان إدراجه في لغتنا القانونية الخاصة ، شأنه شأن استخدامات كثيرة درج الفقه والقضاء ورجال القانون على استخدام في القوانين والأحكام والمؤلفات الحقوقية ، دون أن يكون لها أساس في اللغة الفصحى ، كما في استخدام مصطلح (الغير) و (البعض) وما شاكل ذلك ، والمهم أن يكون لهذا الاستخدام معنى خاص على وفق اللغة المهنية الدارجة . (لاحظ ، بحثاً : قنونة ١) العقد ، منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية ، تصدرها كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية ، اهلم كوردستان-العراق ، السنة الأولى ، العدد (٢) ، كانون الأول ، ٢٠١٣ ، ص (١١) .

(١). لاحظ : د. ماهر عبد شويش و د. محمد سليمان الأحمد و هيثم حامد المصاروة ، نظرية تعادل الأسباب في القانون الجنائي ، دار الحامد ، عمان ، ٢٠٠٠ ، ص١٤ .

(٢). لاحظ: بحثاً ، فكرة التطور القانوني بين تبدل القانون وتغير الواقع (دراسة تحليلية استخلاصية لعنصر (المستقبل) في القاعدة القانونية ، مجلة بحوث مستقبلية ، تصدرها كلية الحداية الجامعة ، العدد الأول ، ٢٠٠٠ ، ص٢٩٧ .

(٣). وهنا يقترب التكيف من القياس ، فأساس الأخير يقوم على فكرة أن النصوص متناهية وأن الوقائع غير متناهية فكيف يمكن أن يدرك المتناهي غير المتناهي (لاحظ: أ.د. مصطفى الزلي ، أصول الفقه الإسلامي في نسجيه الجديد ، مركز عبادي ، صنعاء ، ١٩٩٦ ، ص١٠٤ وما بعدها.) والقياس قد يكون أحد أدوات عملية التكيف لأن الواقعة قد لا يمكن إعطاؤها الوصف القانوني الصحيح ألا بقياسها على واقعة أخرى منصوص عليها ، ثم أن التكيف غير محصور فقط في دائرة الأوصاف المنصوص عليها بل يشمل الأوصاف الموضوعية من قبل المصادر غير النصية أيضاً .

(٤). من الممكن أن يقوم غير القاضي والفقيه بمهمة التكيف ، فرجل الإدارة يمكن أن يقوم بتكيف الوقائع الإدارية المعروضة عليه ، وكذا المحامي فيما يعرض عليه من قضايا .

المبحث الثالث

ماهية الطبيعة القانونية

٨- عندما يتم تعريف قانون ما ، فإنه يتم تعريفه بموضوعاته المدرجة تحت ظله ، فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم المعاملات المدنية ، والقانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتضمن الحقوق والحريات العامة والأساسية و تنظم اختصاصات السلطات الثلاث في الدولة والعلاقة فيما بينها ؛ وهكذا إذن فالقانون هو الذي يحدد طبيعة الوقائع من وجهة النظر القانونية ، إذ إن للأشياء طبائع أخرى من زوايا متعددة ، لكن القانون يحدد طبيعتها القانونية فحسب ، بمعنى القانون المختص بها .

٩- إن القانون عندما يحدد الطبيعة القانونية للأشياء فإنه يحاكي ذات الواقعة في نظره وليس في نظر الواقع ، من هنا يلاحظ أن القانون هو الذي ينشئ الطبيعة القانونية للوقائع ، أما الكشف عن هذه الطبيعة فيتم من قبل من يهتم بالكشف عنها ، فيكون عن طريق عملية يطلق عليها (الإسناد القانوني) ، وهذا الإسناد يختلف عن إسناد مكونات الواقعة ، كأسناد النتيجة إلى الفعل وإسناد الفعل إلى الفاعل ، فالإسناد القانوني يعني نسبة الواقعة إلى قانون يطبق عليها ، فتتحدد طبيعة الواقعة من خلال إسنادها لقانون معين ، والمقصود بالقانون هنا القانون بمعناه الخاص ، أي القانون المختص بالتطبيق — كما ذكرنا في المبحث السابق - ؛ فإذا كانت الواقعة تتعلق بمعاملة مالية خاصة ونحن لا نعرف طبيعة هذه الواقعة ، فهل أن هذه المعاملة مدنية أم تجارية ؟ فإذا أسندنا هذه المعاملة إلى قواعد القانون المدني فقد فهمنا أن هذه الواقعة ذات طبيعة مدنية ، وكذلك الحال فيما لو أسندت الواقعة إلى قواعد القانون التجاري .

١٠- إن الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية يختلف عن الإسناد في القانون الدولي الخاص ، إذ إننا لا نستطيع تطبيق قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص إلا إذا كنا أمام علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي ، أما الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية فيمكن أن يكون في كافة العلاقات القانونية الوطنية الخالصة والمشوبة بعنصر أجنبي . والإسناد الكاشف للطبيعة القانونية ليس حتمياً في كل الوقائع إلا في تلك التي يشك في طبيعتها القانونية ولأي قانون تخضع ؟ بعكس ما رأيناه في التكييف القانوني ، وهذا ما يفرق بين الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية والتكييف القانوني ، لكن ماذا عن الطبيعة القانونية في ذاتها ؟

١١- في الوقت الذي رأينا فيه أن التكييف يتعلق بمقولاتي الفعل والانفعال منطقاً ، نجد أن الطبيعة القانونية تتعلق بمقولة (الكيف) (١) ، أي (كيف) جوهر الواقعة ، إذ إن الطبيعة القانونية ثابتة في الأشياء ، هذا الثبات هو :-

(١) ، لاحظ ما سبق ذكره في الهامش رقم (١٠) من هذا البحث . ولاحظ أيضاً : الأستاذ عبد الرحمن حسن حنكة الميداني ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، دار القلم ، دمشق — بيروت ، ١٩٧٥ ، ط١، ص٣٣٩ .

قانون عن آخر يعتمد ، أساساً ، على موضوع هذا القانون وما يتميز به عن موضوعات القوانين الأخرى ، وموضوع القانون يعني المفردات العامة التي يختص القانون بها ، وهذه المفردات قد أعطاهها القانون طبيعة معينة تجعلها تخضع لقانون معين دون غيره ؛ فإذا أردنا معرفة أن هذه المسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية ، فإننا بصدد تحديد لطبيعتها القانونية ، لأنه بهذا التحديد سيتعين القانون الأول بالتطبيق ، هو القانون المدني (فيما لو كانت المسؤولية مدنية) ، أم القانون الجنائي (فيما لو كانت المسؤولية جنائية) ، أم القانون الإداري (فيما لو كانت المسؤولية إدارية) ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للعقد ، فالعقد إذا كان مدنياً فسنتطبق عليه القانون المدني ، وإذا كان تجارياً فسيختص به القانون التجاري(١) ، وإذا كان إدارياً فيتعين إسناده إلى القانون الإداري ؛ مع ملاحظة الإحالات القانونية إلى القواعد العامة ؛ وهكذا بالنسبة للالتزام بالدفع ، فإذا كان على سبيل الغرامة عدّ الموضوع ذا طبيعة جنائية ، أما إذا كان الدفع على سبيل التعويض فالموضوع ذو طبيعة مدنية ، وأما إذا كان الدفع على سبيل الضريبة فإننا أمام قضية مالية عامة ينطبق عليها قانون الضرائب . وعملية تحديد الطبيعة القانونية للواقعة يمكن أن نطلق عليها بالإسناد كما سيجي بيان ذلك . و- ينقصد التكييف على مرحلتين ، مرحلة إلحاق الواقعة بوصف قانوني يجعلها تخضع لنظم قانوني معين (٢) في قانون معين ؛ ومرحلة توظيف الواقعة لصهرها في فرضية القاعدة القانونية الخاصة بها تمهيدا لتطبيق حكم القاعدة عليها . ولربما يكون بإمكاننا أن نسمي التكييف الأول بـ(التكييف التوصيفي) ، والثاني بـ(التكييف التوظيفي) ؛ ففي الأول نلحق الواقعة بنظامها القانوني ، وفي الثاني نلحقها بحكمها الخاص بها ؛ فمثلاً لو عرضت قضية أمام القاضي تتعلق بمسؤولية مدنية ، فإن عليه أولاً أن يوصف الواقعة فهل هي مسؤولية عقدية أم غير عقدية (تقصيرية) ، وهذا هو التكييف التوصيفي ، وبه تلحق الواقعة إما بنظام المسؤولية العقدية أو بنظام المسؤولية الأخرى ، فإذا وجد القاضي أنها مسؤولية غير عقدية ، فأية فرضية تتصهر بها الواقعة المعروضة ؟ هنا يأتي دور التكييف التوظيفي .

(١) . ينتقد بعض الفقهاء استخدام مصطلح (العقد التجاري) ويبرر انتقاده بأن هذا الاستخدام (يوجي بوجود فئة مستقلة من العقود ذات صفة تجارية بحتة اقتضاها التعامل التجاري ، تقوم إلى جانب العقود المدنية . في حين أن العقود التجارية لا تختلف ، في حقيقتها ، لا من حيث الأركان ولا من حيث شروط الصحة ولا من حيث أسباب الانقضاء ، عن العقود المدنية ، لذلك كبار الفقهاء في فرنسا أنه لا توجد (عقود تجارية) ، بالمعنى الدقيق ، وإنما توجد عقود مسماة توصف بالمدينة أو التجارية تبعاً لصفة أطراف العقد والغرض من التعاقد (لاحظ: د. محمد حسن الجبر ، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٩٨٤ ، ص٣٠ .) وقد أيد بعض الفقهاء هذا الاتجاه (لاحظ: د. علي البارودي ، القانون التجاري اللبناني ، ج٢ ، الدار المصرية ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص٥٠ .

(٢) . النمط القانوني يشمل مجموعة من الفكر القانونية المشتركة في العرض ، وبمجموع الأنماط القانونية يتكون في القانون ما يسمى بالنظام القانوني ، فمثلاً يعد كل من إبرام عقد الزواج والخطبة والمهر وشكل الزواج والتفقة والنسب والدخول والخلوة والمدة والخلع والتفريق والطلاق ، أنماطاً قانونية في نظام الزواج . (لاحظ في تعريف النظام القانوني كل من : د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، ج١ ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ١٩٧٢ ، ص١٨٠ . آ. عبد الباقي البكري وآ. زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، ١٩٨٩ ، ص٢٧ .) .

أ- ثبات قانوني ، فالقانون هو المحدد الأصلي للواقعة .

ب- ثبات نسبي ، لأن القانون قد يغير من الطابع القانوني للأشياء.

ج- ثبات موضوعي ، فالطبيعة ثابتة في الموضوع وإن لم تصل إلى علم من ينبغي إدراكها .

١٢- إن الطبيعة القانونية معلومة وينحصر معرفتها في حقيقة ذهنية رسخها القانون تتعلق بدرجة هذه الواقعة أو تلك ضمن قائمة مجموعة معينة من القواعد القانونية ، يطلق عليها بالمجموعة القانونية ؛ ويقصد بالمجموعة القانونية ، نصوص القانون المشرعة التي تحكم حقلاً من حقول الحياة الاجتماعية الذي تتسم روابطه بوحدة طبيعتها ، فيقال المجموعة المدنية والمجموعة التجارية والمجموعة العقابية (١) .

٣- إن تحديد مفهوم الطبيعة القانونية مرتبط بادرار الكليات الخمس في علم المنطق ، وهي : الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام (٢) . فالجنس مجموعة من أنواع مشتركة في صفات معينة وإن اختلفت في حقائقها ، فالجنس في حالة الإنسان هو الحيوان أما النوع فمجموعة من أشياء مشتركة في حقائقها وإن اختلفت في خصائصها وميزاتها ومشخصاتها ، فالإنسان نوع من الكائنات الحية . أما الفصل فهو ما يميز النوع عن غيره من الأنواع ، فالإنسان نوع ، لكن ما يميزه عن أبناء جنسه من الأنواع الأخرى ، أنه ناطق . أما العرض الخاص فهو استدراك كل النوع وخصائصه وإن لم تبدو فاعلة ، كالضحك عند الإنسان وإن لم يضحك . أما العرض العام فهو صفة غير ذاتية في حقيقة الشيء ، بل تتحقق في أفراد وأفراد غيره ، كوصف التنفس في الإنسان (٣) .

١٤- إن الطبيعة القانونية للأشياء وتكييف الوقائع تتطلب منا تعريف الواقعة وتحديد صفاتها وخصائصها وتمييزها عن غيرها من أنواع الوقائع الأخرى ومن ثم تحديد طبيعتها وتكييفها القانوني . ونبدأ بالتعريف الذي يقصد به (القضية التي تحدد لنا الصفات الجوهرية للشيء ، أو تلك الصفات التي بناءً عليها أطلق عليه اسمه ، فالاسم هو موضوع القضية ، والمحمول هو الصفات التي إذا فقدتها الشيء فقد وجوده معها ، إذ التعريف هو ماهية الشيء وكيانه ، وتلك الماهية مؤلفة من الجنس والفصل وهي متساوية في نطاقها مع الموضوع الذي تعرفه ، أو أن التعريف ينطبق على كل فرد من أفراد الموضوع ، مثل (حيوان ناطق) بالنسبة للإنسان (٤) . فالتعريف هو تحديد ماهية الشيء ، أي جوهره ؛ وتحديد الصفات هو العرض العام ؛ والخصائص هو العرض الخاص ؛ وتمييز الشيء عن ما يشبهه به هو الفصل ؛ تحديد تكييفه القانوني هو تحديد نوعه ؛ وبالنسبة لا يبقى سوى تحديد الطبيعة القانونية للشيء ، أي تحديد جنسه .

(١) . لاحظ : أ. عبد الباقي البكري وأ. زهير البشير ، مرجع سبق ذكره ، ص٣٦ .

(٢) . لاحظ : د. إمام عبد الفتاح إمام ، مرجع سبق ذكره ، ص٩٨ . وأ. د. مصطفى إبراهيم الزلي ، الصلة بين علم المنطق والقانون ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ١٩٨٦ ، ص٢٤ .

(٣) . لاحظ : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (السيد الشريف) ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، (دون سنة نشر) ، الصفحات على التوالي : ٤٨ ، ١٢٤ ، ٩٥ ، ٥٧ ، ٨٦ . لاحظ : الأستاذ عبد الرحمن حسن حبيكة الميداني ، مرجع سبق ذكره ، ص٣٥ . والأستاذ محمد المبارك عبد الله ، المنطق في شكله العربي ، مطبعة وزارة التربية ، بغداد ، ١٩٨٤ ، ط١ ، ص٢٨ وما بعدها .

(٤) . لاحظ : د. إمام عبد الفتاح إمام ، مرجع سبق ذكره ، ص٩٦ .

المبحث الرابع

العلاقة بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية

١٥- العلاقة بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية ، هي علاقة بين الذات والتفاعل مع مفرداته ، فالطبيعة القانونية هي الذات القانونية للواقعة ، فهي جواب للسؤال عن (كيف) لجوهر الذات ، لكن (كيف) هنا من القانون واليه : أما التكييف القانوني فهو عمل يقوم به شخص مختص في القانون له أدواته القانونية في التعامل مع مفردات الذات (ذات الواقعة) ، فيقوم بـ(قوننتها) أولاً من خلال جعل القضية الواقعة قضية قانونية تتطلب وضع حل قانوني لها ، فالتكييف مرتبط بفعل يأتي من خارج الذات ليضفي عليها وصف قانوني تمهيداً لتطبيق حكم القانون عليها .

١٦- وعلى الرغم من اختلاف معنى التكييف القانوني عن معنى الطبيعة القانونية ، فإن هناك علاقة وأوجه للشبه بينهما يمكن تحديد أهمها في الآتي :-

أ- إن محل كل من التكييف القانوني والطبيعة القانونية هو الواقعة ، ولا نعني بالواقعة هنا المعنى الضيق الخاص ، بل المعنى الواسع العام لها ، فهي تعني كل حدث حاصل بإرادة أو بدونها قابلاً للحكم عليه مهما كان ، فيصدق وصف الواقعة على كل ما يمكن أن تترتب الأحكام القانونية عليه ، والواقعة لا تقبل حكم القانون عليها ما لم تكن محلاً للإثبات (١) ، فكل واقعة تقبل الإثبات تصلح أن تكون محلاً للتكييف القانوني والطبيعة القانونية . عليه فإن كل من العقود ، والاتفاقات بين الأشخاص القانونية مهما كانوا ، داخل الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات الدولية ، والمسؤوليات ، والوقائع المادية ، طبيعية كانت أو بفعل الإنسان ، والجرائم سواء أكانت جنائيات أو جنحاً أو مخالفات ، وعقوباتها ، والعفو والصفح ، والخلافة عامة كانت أو خاصة ، شخصية كانت أو عينية ، وكافة المعاملات والحوادث المنشئة لكافة الحقوق عينية أو شخصية أو معنوية ، والقرارات الإدارية ، والأحكام القضائية ، والإجراءات على أنواعها ، وأعمال السيادة ، بل وحتى القرارات التشريعية ، هي وقائع بالمعنى العام لها ، لأنها أحداث قابلة للحكم عليها . فالعقد قابل للحكم عليه بالصحة أو البطلان أو الفسخ ، وكذا الاتفاقات الأخرى ، والمسؤولية تقبل الحكم عليها بترتيب آثارها من عدمه ، وكذا الحوادث طبيعية أو بفعل الإنسان سواء شكلت جريمة أو فعلاً مباحاً ، كما أن أي قرار إداري قابل للحكم عليه بالنفاذ أو التوقف أو البطلان ، وكذا الحكم القضائي فإنه قابل للحكم عليه بالتصديق أو النقض ، فإذا كان مما لا يقبل الطعن ، فإنه يقبل الحكم عليه فقطاً ، وإن لم يكن هذا الحكم ملزماً ؛ بل حتى القوانين والتشريعات ، فهي أحداث قابلة للحكم عليها ، فهل التشريع موافقاً للدستور أم لا ، وهل الدستور معبراً عن إرادة الشعب ، وهل أن هذا القانون أو ذاك مقنعاً ، متزنأ ، عادلاً ، مواكباً للتطور ، قابلاً للتطبيق ، جامداً ، مرناً ، هل حل مشكلة ، أم زاد الطين بلة ، إلخ وأعني

(١) . لاحظ : أ. د. عباس البيودي ، كتابه في قانون الإثبات العراقي ، سبق ذكره ، ص٤٤ وما بعدها . وكتابه في قانون البينات الأردني الجديد ، سبق ذكره ، ص٢٤ وما بعدها .

بالحكم هنا هو الرأي القانوني المبدى في الواقعة من قبل القائم بعملية التكيف أو الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية ، سواء أكان ملزماً ، كالحكم القضائي ، أم غير ملزم ، كأفكار الفقهاء وآرائهم .

ب- إن أدوات كل من القانون في إضفاء الطبيعة القانونية على الوقائع المجردة ، والقائم بعملية الإسناد الكاشف لهذه الطبيعة ، والمكيف القانوني للواقعة ، هي أدوات قانونية ومنطقية ، فالمشروع — على سبيل المثال — هو الذي يحدد الطبيعة التجارية لبعض الأعمال ، كالشراء بقصد البيع ثانية بريح ، ومن ثم لو عرضت قضية تتعلق بعمل مفاد شراء شيء معين لغرض بيعه ثانية بريح ، يصبح لدينا تصوّر عن طبيعة هذه الواقعة وما يصدق عليها(٧) ، لكن كيف نكيفها ؟ فإذا بدأنا بالتكييف التوصيفي وكان شراء الشيء لغرض بيعه ثانية بطريقة البيع الإيجاري ، فهنا نكون أمام تساؤل ، هل أن هذا التصرف بيع أم إيجار ؟ هنا لا بد من استخدام أداة قانونية ومنطقية ، فالحقد (جنس) وله (أنواع) ، ولكل نوع مميزات (تفصله) عن غيره ، وهذه الميزات هي (أعراض خاصة) به نأخذها بعين الاعتبار بعيداً عن (الأعراض العامة) المشتركة بين أكثر من عقد . إذن على القائم بالتكييف أن يدرك عناصر وخصائص كل عقد على حدة ، فإذا توافرت العناصر الجوهرية لأحد العقود في الواقعة المعروضة ، رجحت كفة هذا العقد على العقود الملبّس توافر أوصافها في الواقعة ، الأداة هنا بجانب كونها منطقيّة فهي قانونية ، فالقانون هو الذي يحدد العناصر الجوهرية للعقود ، فعندما يرى القاضي أن التصرف في المثال أعلاه يغلب عليه وصف البيع لتوافر عناصره الجوهرية ، فانه يكون قد انتهى من التكيف التوصيفي ، ليأتي إلى التكيف التوظيفي ، فما هي المشكلة وما هو الحكم القانوني الخاص بها والمطبق على الفرضية الواردة في القاعدة القانونية ، والتي ألحقت الواقعة المعروضة بها ، وهنا سيكيف القاضي المشكلة فهل هي تتعلق بإبرام العقد أم تنفيذه أم فسخه وانقضائه ؟؟ بأداة قانونية منطقية .

ج- ولا ننسى أن كل من التكيف القانوني والطبيعة القانونية يلعب دوراً مهماً في القانون الدولي الخاص ؛ إذ إن من يريد أن يكيف واقعة ما مشوبة بعنصر أجنبي ، أو يحدد طبيعتها القانونية ، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى إخضاع هذه الواقعة لقانون ما ؛ معنى هذا: أن التكيف القانوني يشترك مع الطبيعة القانونية في أنها — بتحديدتهما وتعيينهما — يهدفان إلى تعيين القانون الواجب التطبيق على الواقعة التي تتنازع عليها عدة قوانين ؛ لكن ما هي نوعية القانون الذي يراد إخضاع الواقعة لاختصاصه؟

١٧- يميل غالبية المختصين في علم القانون موضوعاً مهماً في المدخل إلى دراسة هذا العلم ، ألا وهو تحديد المعنيين العام والخاص للقانون ، وقد سبق لنا أن حددنا هذين المعنيين ، وبعد إدراك هذين المعنيين للقانون ، يلاحظ أن العملية تمر بمراحل حتى نصل إلى هدف كل من التكيف وتحديد الطبيعة ، وما لهذين النماطين القانونيين من دور فاعل في اختيار القواعد القانونية التي يشتمل عليها القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي . إن تحديد القانون

(١) . التصور هو مدرك ذهني مرتبط بالمفهوم ويقصد بالمفهوم المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان ، واللفظ دلالة كلامية عليه . وأما الماصدق أو (المصادق) فهو الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه الذهني . (لاحظ : الأستاذ عبد الرحمن حسن جبنة الميداني ، مرجع سبق ذكره ، ص:٤١) .

الواجب التطبيق على واقعة ما ، وثيق الصلة بكل من المعنيين العام والخاص للقانون ، سواء أكان القانون المراد معرفته ، واجب التطبيق على علاقة دولية أو علاقة وطنية غير مشوبة بعنصر أجنبي ، فالهمم بالنسبة للعلاقات الدولية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي ، هو تحديد القانون بمعناه العام ، ما دام هناك عدة قوانين لدول مختلفة تتنازع في التطبيق على ذلك النوع من العلاقات ، لذا فإن حل النزاع بين هذه القوانين ، لا يتم إلاً بتحديد أي من هذه القوانين هو واجب التطبيق على تلك العلاقات(١) ، كأن يرم شخص عراقي عقداً في الأردن مع شخص سوري لغرض تنفيذه في لبنان ، (المثال المطروح آنفاً) (٢) ، فأي من هذه القوانين هو الواجب التطبيق على هذا التصرف (الواقعة بمعناها العام) ؟ .

١٨- لكن العملية لم تنته بعد ، إذ أن تحديد القانون الأردني - مثلاً - في مثالنا أعلاه، على العلاقة الدولية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي ، لم يحل سوى بعض المشكلة ، إذ بقي تحديد مسألتين مهمتين هما:

أ- تحديد نوعية القانون المطبق على الواقعة ، فلا يكفي أن نقول أن القانون الأردني هو الواجب التطبيق عليها ، بل لا بد من تحديد نوعية هذا القانون ، أهو القانون المدني ، أم القانون التجاري ، أم قانون المالكين والمستأجرين ؟ وبهذا التمييز يتحدد القانون بمعناه الخاص . وهو لا غنى عنه في العلاقات الدولية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي، ولا غنى عنه في العلاقات الوطنية الصرفة كذلك .

ب- تحديد نوع الواقعة ، فإن كانت عقداً فهل هو عقد بيع أم هبة أم إيجار .. ، إلخ ، وإن كانت مسؤولية ، فهل هي مسؤولية تقصيرية أم عقدية ؟؟

ومن خلال تحديد هاتين المسألتين في الموضوع ، يتضح لنا أن المسألة الأولى ، إنما تتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للواقعة ، أما المسألة الثانية فتتعلق بالتكيف القانوني لها ، فالطبيعة القانونية تمنى إخضاع الواقعة لقانون (بمعناه الخاص) ، أي لتنظيم قانوني معين ، أما التكيف القانوني فيعني إعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة .

١٩- لكن علينا أن نشير إلى نقطتين مهمتين هما :

أ- قد يظن البعض أنه من الواجب - أولاً - تحديد القانون بمعناه الخاص ، ثم التحول إلى تعيين القانون بمعناه العام ، فيما لو كانت العلاقة مشوبة بعنصر أجنبي، على أساس أن القاضي عندما يطبق قانوناً أجنبياً على علاقة دولية خاصة ، فإن أول عمل يقوم به هو (تكيف) تلك العلاقة(٣) ، ومن ثمّ تعيين القانون بمعناه العام .

(١) . لاحظ: د. حسن الهداوي ود. غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص ، القسم الثاني ، دار الكتب ، الموصل، ١٩٨٨ ص ١١ .

(٢) . لاحظ: الفقرة (٣) من البحث .

(٣) لاحظ: د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونيين العراقي والمقارن ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٧ ، ص٢٦٠ . ولاحظ أيضاً : د. حسن الهداوي ، تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ١٩٧٢ ، ص ٥٩ وما بعدها .

صحيح إن أول مرحلة من مراحل تطبيق القانون الأجنبي تكمن في التكيف ، لكن يجب إدراك معرفة المفهوم الدقيق للتكيف في مجال القانون الدولي الخاص من جهة ، وفي مجال المعاملات المالية من جهة أخرى ، فالتكيف - كما مرّ بنا - هو : (تحديد الوصف السليم للرابطة القانونية المطروحة أمام القاضي لينتهي إلى كون العقد محل النزاع هو عقد إيجار أو عقد بيع ... الخ) (١) ؛ فالغاية من التكيف - إذن - كما يقول بعض الفقهاء (٢) - هي : (وصل الحالة القانونية بإحدى الفكر المسندة لا بأحد النظم القانونية كما يقال عادةً ، لأن تقسيم الأنظمة القانونية ليس مطابقاً لتقسيم الفكر المسندة ، بل أن ثمة فكرياً مسندة لا تعتبر بذاتها مكونة لأنظمة قانونية كأثار الزواج وأشكال التصرفات) ، لذا فإن تحديد وصف العقد بأنه يدخل ضمن نطاق القانون المدني أو القانون التجاري ، هو ليس تكيفاً له ، بل تحديداً لطبيعته القانونية التي توصلنا بالنهاية إلى تحديد القانون بمعناه الخاص ، وهذا هو الفرق بين التكيف القانوني والطبيعة القانونية .

أما ما يتعلق بتحديد نمط الواقعة من حيث انتمائها لنظام محدد ، فهو استاذ لها وليس تكيفاً ، فتحديد وصف الواقعة يختلف عن تحديد وصف المشكلة التي انقدحت بها مشكلة التنازع بين القوانين ، فهكون المشكلة الأخيرة متصلة بكون المسألة هي مسألة أهلية أم شكل - على سبيل المثال - ، هي وجه أخير لاستناد الواقعة لنظام ، وهذا يدخل في الطبيعة لا في التكيف .

ولغرض تعيين القانون الواجب التطبيق على العقد - مثلاً - ، يجب أولاً تكيف هذا العقد ، ومن ثمّ تحديد القانون بمعناه العام ، على فرض وجود عنصر أجنبي في العقد ؛ هذا إذا لم يلتبس على القاضي تحديد وصف المشكلة التي خلقت وضع التنازع ، فهو يحتاج لتحديد الطبيعة القانونية لهذا الوجه فقط ، ومن ثمّ يُسند الواقعة الى قانونها ، أي أنه يقوم بتعيين القانون بمعناه الخاص (تحديد الطبيعة القانونية) .

ب- إن كون العلاقة القانونية ، علاقة دولية خاصة (٣) مشوبة بعنصر أجنبي ، أو علاقة وطنية العناصر ، لا يغير من طبيعتها القانونية ، فالعقد - مثلاً - إذا كان عقداً مدنياً ، فإنه يبقى بهذا الوصف ، وإن شابه عنصراً أجنبياً ، مما يعني أن العقود المدنية والتجارية ، من الممكن أن تكون دولية مثلما يمكن أن تكون وطنية ، ذلك لأنها تعمد من عقود القانون الخاص (٤) .

(١) . لاحظ: د. هشام علي صادق . مرجع سبق ذكره ، ص ١١١ .

(٢) . د. محمد كمال فهمي ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٢٧ .

(٣) العلاقات الدولية إما أن تكون عامة أو خاصة ، فالعلاقات الدولية العامة هي القائمة بين الدول أو بينها والمنظمات الدولية العامة ، أما العلاقات الدولية الخاصة فهي القائمة بين الأفراد (رعايا الدول) ، أو بين الأشخاص المعنوية الدولية الخاصة غير الحكومية ، والفرق بين النوعين من العلاقات الدولية ، أن العامة منها تخضع لقواعد القانون الدولي العام ، أما الخاصة منها فتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص .

(٤) في المعنى نفسه لاحظ : د. حسن الهداوي و د. غالب الداؤودي ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٢ وما بعدها .

الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي:-

٢٠- النتائج ؛ ويمكن إجمالها في الآتي :

أ- يختلف مفهوم التكيف القانوني عن مفهوم الطبيعة القانونية ، في حين يعني التكيف إعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعة المعروضة ، تعني الطبيعة القانونية نوعية الواقعة من وجهة النظر القانونية ، فالتكيف يتصل بعمل يقوم به القاضي أو الفقيه في العادة ، فهو مرتبط بمقولتي الفعل والانفعال في علم المنطق ، أما الطبيعة القانونية فهي متعلقة بمقولة الكيف في علم المنطق .

ب- لتحديد الفصيل بين التكيف القانوني والطبيعة القانونية أهمية بالغة في تحديد نطاق القانون المختص ، فالطبيعة تحدد نوع القانون المطبق ، (القانون بمعناه الخاص) ، كما لو كان قانوناً مدنياً أو قانوناً تجارياً أو قانوناً للأحوال الشخصية أو ما إلى ذلك ، أما التكيف فهو انطلاقة تطبيق القانون على الواقعة ، إذ به (تقنون) الواقعة ، فتظهر في فرضية القاعدة القانونية ليطبق عليها بعدد حكم القاعدة الوارد على فرضيتها ، وهذا ما دفعنا إلى تقسيم التكيف إلى نوعين ، تكيف توصيفي وتكيف توظيفي .

ج- إن محل كل من التكيف والطبيعة هو الواقعة بمعناها العام ، الذي به يقصد بالواقعة كل حدث يقع ويكون قابلاً لترتيب الحكم عليه ، والواقعة تكون صالحة لأن تكون محلاً لكل من التكيف والطبيعة ، متى ما كانت صالحة محلاً للإثبات.

د- القانون هو الذي يحدد الطبائع القانونية للوقائع ، وعادة ما يكون لدى رجل القانون تصور عن هذه الطبائع ، لكن إن التيس عليه الأمر ، فإن عليه أن يقوم بعملية الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية.

هـ- إن لكل من التكيف القانوني والطبيعة القانونية دوراً مهماً في القانون الدولي الخاص ، في حالة وجود العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي ، إذ إن قواعد الإسناد في هذا القانون تشير دوماً إلى القانون الواجب التطبيق على الواقعة ، من خلال تحديدها (للقانون بمعناه العام) ؛ لكن العملية تتطلب كذلك تعيين (القانون بمعناه الخاص) في الدولة التي أشارت قواعد الإسناد إلى اختصاص قانونها ، وهنا يتحتم الرجوع إلى الإسناد الكاشف للطبيعة القانونية ، وقبل هذا ينبغي أولاً معرفة وصف الواقعة ، وهنا يأتي دور التكيف القانوني .

- ٢١- التوصيات : ويمكن إجمالها في الآتي :
- أ- إجراء الدراسات المعمقة في تحديد ماهيَّات المصطلحات المستخدمة في كل الدراسات القانونية ، كمصطلحات : الأساس القانوني ، والتأصيل القانوني ، والإطار القانوني ، والنظام القانوني ، والوضع القانوني ، والمركز القانوني ، وكذلك التكيف القانوني والطبيعة القانونية .
- ب- استخدام الأدوات المنطقية في التمييز بين الأنماط القانونية المختلفة ، سواء تلك الأنماط المتعلقة بأحكام الفقه القانوني ، أو تلك المتعلقة بأصول الفقه القانوني .
- ج- وضع منهج جديد في كليات القانون تحت عنوان (أصول الفقه القانوني) ، يتناول دراسة كيفية التعامل مع النصوص القانونية والتعريف بالمبادئ القانونية والقواعد الكلية والدلالات واستنباط الأحكام والتحليل والتكييف والتفسير وما إلى ذلك ، والاستفادة من تراثا الإسلامي الغني في هذا المجال والمتمثل في أصول الفقه الإسلامي .
- النص في القانون المدني على تعريف المصطلحات القانونية العامة المتعلقة بأصول التفسير والتكييف ، ووضع فواصل لمعاني كل المصطلحات القانونية.
- هـ - العمل على سن قانون التفسير العام للنصوص وأصول تطبيقها ، ليكون معيناً للقضاء في تفسير القوانين ، وبالتالي حسن تطبيقها تحقيقاً للعدالة .

قائمة المراجع

١. أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجر جاني (السيد الشريف) ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، (بدون سنة نشر) .
٢. د. إمام عبد الفتاح إمام ، محاضرات في المنطق ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
٣. د. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر ، الأصول العامة للقانون ، الدار الجامعية ، بيروت ، ١٩٨٩ .
٤. د. حسن الهداوي ، تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ١٩٧٢ .
٥. د. حسن الهداوي ود. غالب الداؤودي ، القانون الدولي الخاص ، القسم الثاني ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٨٨ .
٦. د. رؤوف عبيد ، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٤ ، ط٤ .
٧. د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبد المال ، القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، ١٩٩٥ .
٨. د. سعيد مبارك ، أصول القانون ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٨٢ .
٩. أ. د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٩٧ ، ط٢ .
١٠. أ. د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات الجديد ، دار الثقافة ، عمان ، ٢٠٠٤ .

١١. أ. عبد الباقي البكري و أ. زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، ١٩٨٩ .
١٢. أ. عبد الباقي البكري ود. علي محمد بدير و أ. زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، دار الكتب ، الموصل ، ١٩٨٧ .
١٣. د. عبد الرحمن حسن حنكة الميداني ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، دار القلم ، دمشق ، بيروت ، ١٩٧٥ ، ط١ .
١٤. د. عبد الرؤوف مهدي ، الاتجاهات المعاصرة في أساس ونظام إباحة الجريمة الرياضية ، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة ، القاهرة ، العدد الثالث ، السنة ٢٧ ، ١٩٨٣ .
١٥. د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٩ ، ط٩ .
١٦. د. علي البارودي ، القانون التجاري اللبناني ، ج٢ ، الدار المصرية . بيروت ، ١٩٧١ .
١٧. د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، ج١ ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، ١٩٧٢ .
١٨. د. ماهر عبد شويش ود. محمد سليمان الأحمد وهيثم حامد المصاروة ، نظرية تعادل الأسباب في القانون الجنائي ، دار الحامد ، عمان ، ٢٠٠٠ .
١٩. أ. محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة الإسلامية ، مكتبة الهلال ، (بدون مكان وسنة نشر) .
٢٠. د. محمد حسن الجبر ، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٩٨٤ .
٢١. د. محمد سليمان الأحمد ، تنازع القوانين في العلاقات الرياضية الدولية ، دار وائل للنشر ، عمان ، ٢٠٠٤ .
٢٢. محمد سليمان الأحمد ، عناصر القاعدة القانونية (الفرضية والحكم) ، بحث منشور في مجلة الراغبين للحقوق ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد الخامس ، ١٩٩٨ .
٢٣. محمد سليمان الأحمد ، فكرة التطور القانوني بين تبدل القانون وتغير الواقع ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، كلية الحدياء الجامعة ، العدد الأول ، ٢٠٠٠ .
٢٤. د. محمد سليمان الأحمد ، المسؤولية المدنية للمساهمين في تنظيم الأنشطة الرياضية ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، ٢٠٠٠ .
٢٥. محمد سليمان الأحمد ، الوضع القانوني لعقود انتقال لاعبي كرة القدم المحترفين ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، ١٩٩٧ .
٢٦. د. محمد سليمان الأحمد ود. نضال ياسين حمو ، المنشطات الرياضية ، دار جهينة للنشر ، عمان ، ٢٠٠٣ .
٢٧. أ.د. محمد سليمان الأحمد ، (فتونة ١) العقد ، منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية ، تصدرها كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية ، اقليم كردستان-العراق ، السنة الأولى ، العدد (٢) ، كانون الأول ، ٢٠١٢ .

بين الوسيط والعمل في الأوراق المالية الصادرة عن

شركات المساهمة في القانون البحريني والقانون المصري

الدكتور/ عماد رمضان

أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية الحقوق – جامعة المملكة – مملكة البحرين

مقدمة :- التعريف بموضوع البحث

تصدر شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام أوراقاً مالياً عبارة عن الأسهم والسندات ، والتي يصرح لها القانون بإصدار أوراقاً مالية تطرح في اكتتاب عام بهدف إما تجميع رأس المال بإصدار أسهم أو الحصول على المال اللازم لتسيير أمور الشركة أثناء عملها عن طريق طرح سندات للاكتتاب العام ، ويتم التعاقد مع جمهور المكتتبين عن طريق أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المرخص لها بتلقي الاكتتابات، وقد تهدف الشركة المساهمة من ذلك في الرغبة الى زيادة رأس المال، ونظراً لأن المشرع في قانون الشركات سواء البحريني أو المصري نظم قواعد خاصة بشركات المساهمة، بأن جعل الاعتبار المالي فيها هو الأساس ومن ثم يكون للمساهم كامل الحرية في الدخول أو الخروج منها دون أن تتأثر الشركة بكيانها القانوني، خلافاً لشركات التضامن ، والتي تنتهي بمجرد خروج الشريك أو وفاته أو فقد أهليته لوجود اعتبار شخصي ومهم للشريك المتضامن، وحرية خروج ودخول المساهمين بشركة المساهمة هو سر نجاح هذه الشركات في الوسط الاقتصادي لأي دولة وهو ما جعل المشرع ينظر اليها بعين الاعتبار خلافاً للشركات الأخرى، كذلك، وقد نظمها بنصوص قانونية خاصة، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو بنشاطها أو مقدار رأس المال فيها .

ورأسمال الشركة المساهمة بصفة عامة ينقسم الى أسهم متساوية القيمة ، يعبر السهم عن جزء من رأس المال يكون للمساهم المكتتب فيه ، ويعطيه حقوفاً ويفرض عليه عدة التزامات ، ومن أهم هذه الحقوق والتي تمثل دراستنا هو حق الخروج من الشركة بتنازله عن سهمه أو أسهمه الى الغير أو الشركة نفسها والحصول على قيمة السهم الإسمية التي دفعها عند دخوله الشركة بالإضافة الى نصيبه في الأرباح التي تحققت بالشركة ، والقاعدة أن الشركة تتولى إتمام عملية التنازل وتقيد ذلك في دفاترها الخاصة بالأوراق المالية، إلا أن هذا الأمر قد يشغل الشركة عن إدارة مشروعها ، فتعهد به الشركة الى شركة أخرى أو شخص آخر بإجراء هذه العملية يسمح له القانون بمباشرة هذه العملية لصالح الشركة المصدرة للأوراق المالية، وهو ما يطلق عليه الوسيط، أي الذي يتوسط في شراء أو بيع الأسهم أو السندات لصالح الشركة أو العملاء ، بل أن المشرع سواء بالبحرين أو بمصر أنشأ سوقاً يسمى سوق الأوراق المالية بهدف الترخيص لشركات المساهمة بإصدار أوراق مالية (الأسهم والسندات) والرقابة على تداول الأسهم ومراقبة الأسعار التي يتم من خلالها بيع الأوراق المالية، بهدف منع التلاعب في أسعارها وحدوث مضاربات قد تضر بالشركة ذاتها أو بالمساهمين، وغالباً ما يكون للوسيط الدور الأكبر في هذه العملية، لأسباب حاصلها أنه أول من يتطلع على الأسعار اليومية للأوراق المالية ، ومن خلالها يقرر البيع أو الإنتظار لحين حدوث ارتفاع رغم عدم تلقيه أمراً من المساهم أو صاحب السند (العميل) .

٢٨. د. محمد كمال فهمي ، أصول القانون الدولي الخاص ، دار الطالب ، الإسكندرية ، ١٩٥٥ .

٢٩. أ. محمد المبارك عبد الله ، المنطق في شكله العربي ، مطبعة وزارة التربية ، بغداد ، ١٩٨٤ ، ط١ .

٣٠. أ. د. مصطفى إبراهيم الزلي ، أصول الفقه الإسلامي في تسيجه الجديد ، مركز عبادي ، صنعاء ، ١٩٩٦ .

٣١. أ. د. مصطفى إبراهيم الزلي ، الصلة بين علم المنطق والقانون ، مطبعة شفيق ، بغداد ، ١٩٨٦ .

٣٢. أ. مصطفى كامل ياسين ، كيف يطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٩٥٧ .

٣٣. د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٧ ، ط٢ .

٣٤. د. هدى سالم الأطرقي ، التكيف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي ، أطروحة دكتوراه في كلية القانون ، جامعة الموصل ، ٢٠٠٠ .

٣٥. د. هشام علي صادق ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٧٥ .